N° 490157 M. O…

Section du contentieux

Séance du 6 décembre 2024
Lecture du 19 décembre 2024

CONCLUSIONS

Mme Maïlys LANGE, Rapporteure publique[1]

1. Maintenant que vous avez été brillamment éclairés par les conclusions de notre collègue Jean-François de Montgolfier[2] sur le cadre juridique d'ensemble de l'incorporation du droit de se taire en matière disciplinaire, il vous faut procéder aux réglages fins, afin de vous assurer de donner à cette garantie constitutionnelle toute la portée qui découle de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sans enrayer une mécanique disciplinaire qui l'avait jusqu'alors ignorée. La présente affaire, qui, à la différence de la précédente, concerne un agent public qui vous saisit d'un recours pour excès de pouvoir, vous permettra ainsi de vous prononcer sur trois ensembles de questions, concernant d'abord le champ d'application temporel et organique du droit de se taire s'agissant des enquêtes conduites par l'administration avant, ou en parallèle, de poursuites disciplinaires, puis les conséquences à tirer en cas de défaut de notification dans une procédure de sanction administrative. Il s'agira aussi de donner aux administrations, qui les attendent, sinon un mode d'emploi, du moins quelques indications sur les modalités selon lesquelles il leur appartient de notifier ce droit.

2. M. N… O…, qui exerce depuis 2010 les fonctions de vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de XX…, vous demande l'annulation[3] de la décision par laquelle le garde

[1] Nous exprimons notre reconnaissance à notre collègue Maxime Boutron, qui devait conclure sur une affaire initialement inscrite au rôle de la Section du contentieux le même jour, pour sa contribution déterminante à ces conclusions.
[2] Conclusions sur CE, Section, 19 décembre 2024, *S...*, n° 490952
[3] Pour excès de pouvoir, contrôle que vous exercez depuis une décision de Section *H...* du 18 décembre 1936 (p. 1126), réaffirmée sous l'empire de la Constitution de 1946 par une décision *D...* (12 janvier 1949, p. 16) et sous celui de la Constitution de 1958 par une décision *A...* (21 février 1968, n° 68170, p. 122), alors que vous êtes juge de cassation des décisions disciplinaires du CSM dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

des Sceaux, ministre de la justice, lui a infligé, après enquête de l'Inspection générale de la justice et avis motivé du CSM dans sa formation compétente en matière de discipline des magistrats du parquet[4], la sanction de déplacement d'office, pour des manquements, d'une part, à ses devoirs de loyauté, d'impartialité et de probité, pour avoir dirigé pendant près de quinze mois une enquête pénale sensible et d'une ampleur certaine, en dehors de ses attributions et sans en informer sa hiérarchie, alors qu'il connaissait à titre professionnel et privé la fille de l'une des victimes ; et d'autre part, à son devoir de délicatesse, du fait d'insuffisances professionnelles persistantes révélant qu'il ne s'inscrivait pas dans la collectivité de travail du parquet[5]. La décision relève également l'état de santé défaillant de M. O… tout en estimant qu'il ne saurait l'exonérer de manquements déontologiques établis.

Par un mémoire déposé le 12 juillet 2024, soit peu de temps après que le Conseil constitutionnel eût déclaré contraires à la Constitution, par sa décision n° 2024-1097 QPC du 26 juin déjà évoquée[6], les mots : « le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause » figurant à l'article 52, et « le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés » figurant à l'article 56, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (l'ordonnance statutaire), qui sont relatives à la procédure disciplinaire applicable aux magistrats du siège mais aussi, par l'effet des renvois internes à l'ordonnance[7], aux magistrats du parquet, M. O… a invoqué cette déclaration d'inconstitutionnalité, comme il pouvait le faire en vertu de l'article 2 de la décision du Conseil constitutionnel, sa requête ayant été introduite à la date de publication de cette décision et non jugée définitivement[8]. Il soutient que la décision attaquée du Garde des Sceaux a été rendue au terme d'une procédure irrégulière[9], dès lors qu'il a été entendu sur les manquements qui lui étaient reprochés sans

---

siège, qui statue alors en qualité de juridiction administrative (Ass., *Sieur L...*, 12 juillet 1969).

[4] En vertu de l'article 65 de la Constitution

[5] D'autant plus importante que le parquet est indivisible, l'acte accompli par l'un des membres du ministère public l'étant dès lors au nom du parquet tout entier, règle suggérée par l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : « *Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet* »

[6] Conclusions de Jean-François de Montgolfier préc.

[7] Les articles 52 et 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui sont relatifs à la discipline des magistrats du siège sont également applicables aux magistrats du parquet, par l'effet des renvois prévus, respectivement, aux articles 63-3 et 64.

[8] C'est-à-dire n'ayant pas donné lieu à une décision devenue irrévocable (CE 28 nov. 2016, Ministre des finances et des comptes publics c. SAS Autoguadeloupe Développement, n° 390638)

[9] La requête initiale comprenait un autre moyen de légalité externe, certes non repris dans le mémoire produit dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 611-22 du CJA et donc regardé comme abandonné (CE 3 mai 1995, *Société Gherardi*, n° 134993), mais qui suffit à notre sens pour que le moyen d'irrégularité de la procédure

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

avoir jamais été préalablement informé du droit qu'il avait de se taire. Plus précisément, il estime n'avoir pas été informé de ce droit, alors qu'il aurait dû l'être, « *ni au cours de l'enquête administrative engagée à la suite de la révélation des faits litigieux, ni au cours de la procédure disciplinaire engagée contre lui, ni devant le Conseil supérieur de la magistrature, ni même par le Garde des Sceaux avant que celui-ci ne prenne la sanction contestée* ».

Le mémoire en défense du Garde des sceaux, qui produit le PV d'audition de M. O... par la rapporteure désignée par le CSM parmi ses membres afin de procéder à l'enquête disciplinaire, nous permet de rectifier partiellement cette assertion, puisqu'il s'avère que M. O... a bien été informé de son droit de se taire avant cette audition – nous y reviendrons. Mais son moyen vise plus large et pour y répondre, vous devrez vous poser trois séries de questions : en premier lieu, quel est le champ d'application de l'obligation d'information sur le droit de se taire en matière disciplinaire ? Ce droit s'applique-t-il aux enquêtes administratives diligentées avant et en parallèle de l'engagement d'une procédure disciplinaire ? Autrement dit, l'Inspection générale de la justice aurait-elle dû notifier à M. O... son droit de se taire avant de l'entendre pendant presque trois jours pour les besoins de l'enquête administrative qui lui a été demandée par le garde des Sceaux ? en deuxième lieu, à quel(s) moment(s) et sous quelle forme l'information sur le droit de se taire doit-elle être délivrée ? L'information donnée oralement à M. O... par la rapporteure désignée par le CSM avant qu'elle procède à son tour à son audition, cette fois pour les besoins de l'enquête disciplinaire, était-elle suffisante pour couvrir également les phases ultérieures de la procédure et en dépit de sa nature d'avertissement seulement oral ? Et, en troisième lieu, à supposer qu'une réponse positive soit apportée à la première question, ou une réponse négative à la deuxième – c'est-à-dire si vous deviez juger que l'information donnée était soit tardive, soit insuffisante -, quelles conséquences en tirer quant à la légalité de la décision du garde des Sceaux attaquée ? Dans quelles hypothèses un vice tiré de la méconnaissance de cette obligation d'information doit-il entraîner l'annulation de la sanction prononcée ?

3. La première question, qui porte sur la **phase d'enquête administrative**, nous semble la plus délicate. Rappelons tout de suite que le Conseil constitutionnel dans son récent flux de jurisprudences, a jugé que les exigences issues de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : « (…) *impliquent que le professionnel* ***faisant l'objet de poursuites disciplinaires*** *ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du*

---

ne soit pas considéré comme une « demande nouvelle » au sens de la jurisprudence *Intercopie* (CE Section 20 février 1953, n° 9772).

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

droit qu'il a de se taire » (point 9 de la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, M. Yannick L). Il n'a donc pas appliqué le principe de valeur constitutionnelle qu'il avait dégagé à la phase préalable aux poursuites. L'interprétation à en tirer, et que confirme d'ailleurs le commentaire aux Cahiers de la décision relative aux magistrats[10], est que le juge constitutionnel a entendu que ce principe découlant de l'article 9 ne s'applique qu'à compter du moment où la personne est officiellement poursuivie. Mais la question nous apparaît cependant plus complexe qu'il n'y parait. Nous distinguerons dans ce qui va suivre, la question générale d'une procédure administrative qui précède une procédure disciplinaire, où il y a donc une succession chronologique, du cas sans doute moins fréquent de la présente espèce, où les deux procédures sont contemporaines, conduites en parallèle, mais relèvent organiquement d'autorités distinctes.

La phase pré-disciplinaire est soumise à des contraintes contradictoires propres à son essence dont il vous faut tenir compte. Et c'est cette difficulté qui justifie que vous vous prononciez.

La première contrainte, qui irait dans le sens d'une étanchéité, prenant au mot la décision du Conseil constitutionnel, et aboutissant à une inopérance du moyen en dehors de la phase disciplinaire, a trait au pouvoir hiérarchique et au devoir d'obéissance et de transparence dans l'administration en général – nous évoquerons ultérieurement le cas, peut-être particulier, de la magistrature judiciaire. L'article 20 de la Constitution prévoit que « *Le Gouvernement…dispose de l'administration* ». Il ne saurait donc être envisagé un droit au silence généralisé des agents publics. Chacun conçoit ici que le management quotidien d'équipes d'agents publics aboutit, il le faut, à un dialogue. Le responsable hiérarchique d'une collectivité d'agents, qu'il soit chef de bureau, sous-directeur ou secrétaire général de préfecture, doit naturellement en cas d'incident, qui se produirait entre différents agents placés sous son autorité, recueillir les témoignages nécessaires à la non-réitération d'un comportement problématique qui lui serait rapporté, en particulier s'il semble de prime abord isolé et qu'il apparaît possible d'y remédier. Il y a là le rôle classique du chef qui s'assure au quotidien des bonnes relations de travail et qui est en droit d'attendre que les agents qui relèvent de lui, lui répondent. L'article L. 121-10 du code général de la fonction publique prévoit ainsi que *« l'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique* ». Cette étanchéité du droit de se taire à la phase non-disciplinaire fait sens au regard de deux arguments complémentaires : tout d'abord, l'administration peut très bien ne rien savoir sur l'issue qui sera choisie, ne rien prévoir d'autre que l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, dénué de toute finalité répressive, lorsqu'elle s'engage dans une mise en

[10] Décision 2024-1097 QPC, voir le commentaire page 16

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

lumière ou un retour d'expérience ; et par suite, il est difficile de reconnaître un droit pour le mis en cause de ne pas s'auto-incriminer lorsqu'il n'est encore accusé de rien. Le droit au silence n'est, pour ainsi dire, pas naturel au domaine de la répression administrative. Au contraire, comme il a pu être indiqué par la doctrine[11] et dans le sens qui vous a déjà été indiqué par J.-F. de Montgolfier, « *les garanties du droit de la répression administrative ont davantage été conçues comme un « droit à parler » à travers le développement des principes généraux des droits de la défense* ». Cette inopérance s'inscrirait, outre les solides fondements récents qu'elle trouve dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans la ligne de votre jurisprudence qui tend à éviter de faire rejaillir les vices qui ont pu affecter l'enquête administrative dans une phase amont sur la procédure disciplinaire proprement dite[12].

Mais la seconde contrainte dont l'administration doit tenir compte tient aux garanties propres à la procédure disciplinaire, qu'il ne s'agirait pas de méconnaître en retardant abusivement la notification du droit de se taire : à trop d'inopérance, le risque est en effet grand, si la notification est limitée à la procédure disciplinaire, que les moments qui la précèdent ou l'entourent soient maximisés et détournés pour obtenir l'auto-incrimination du mis en cause, à rebours de ce qu'a souhaité le Conseil constitutionnel. Dans l'entre-soi initial d'une procédure pré-disciplinaire, dont rien ne dit, et rien ne laisse entendre, qu'elle sera suivie d'une procédure disciplinaire, un agent public, mis en cause mais pas mis en accusation, peut être tenté, dans une logique de médiation, de reconnaître l'existence matérielle de faits qu'il regrettera ensuite d'avoir avoués, une fois confronté à une sanction disciplinaire qui se nourrirait exclusivement de ces déclarations initiales. Dans des échanges administratifs sur un incident, la pénitence peut venir facilement pour que les choses n'aillent pas plus loin. Pour être schématique et mobiliser l'exemple de la procédure pénale, il y a là le même enjeu que celui qui consisterait à faire parler un gardé à vue en urgence avant l'arrivée de son avocat. C'est la raison pour laquelle les différentes jurisprudences, celle du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme pour la matière pénale, la vôtre pour les autorités administratives dotées de pouvoirs de sanction, ont prévu des pares-feux portant sur ces périodes initiales d'enquête où les droits de la défense ne sont pas pleinement invocables. Il s'agit d'une jurisprudence de compromis dont vous pourriez souhaiter vous inspirer aujourd'hui.

[11] P.-O. Rigaudeau, « La pénalisation de la répression administrative et l'affirmation du droit au silence », AJDA 2024 p.1051

[12] CE, 4/1 ssr, 29 juillet 1994, M..., n° 122492, T. p1165

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

Commençons par la matière pénale : le critère que le Conseil constitutionnel a manié pour faire application du droit de se taire à des phases assez détachées, chronologiquement et organiquement, de la juridiction appelée à prononcer la sanction, par exemple pour l'audition d'un mineur par la protection judiciaire de la jeunesse[13] ou l'examen psychologique réalisé à la demande du Procureur[14], consiste à rechercher si les propos tenus par la personne à cette occasion, alors qu'elle est déjà suspectée d'avoir commis les faits sur lesquels elle est entendue, sont susceptibles d'être portés à la connaissance de la juridiction de jugement, ce qui, par transposition à la procédure disciplinaire, signifierait l'autorité titulaire du pouvoir de sanction, notamment lorsque ces auditions peuvent donner lieu à des procès-verbaux qui alimentent le dossier disciplinaire. Le Conseil constitutionnel a admis l'étanchéité entre les phases de la procédure mais il s'est aussi montré sensible au risque que son caractère trop strict ne conduise les enquêteurs à retarder volontairement le placement en garde à vue d'un suspect entendu librement dans l'espoir d'obtenir des aveux à un stade où la personne n'a pas encore bénéficié de l'assistance d'un avocat. C'est pourquoi tout en validant le principe d'une audition libre d'un suspect, au cours de laquelle les droits du gardé à vue ne s'appliquent pas, il a jugé que le respect des droits de la défense impliquait néanmoins de notifier certains droits, dont celui de quitter les lieux à tout moment, lorsqu'il apparaît « *qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue* »[15]. Il en va de même pour la comparution devant le juge des libertés et de la détention s'agissant de la détention provisoire[16]. Ce critère du « soupçon » vient d'être réitéré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, *Syndicat de la vallée de l'Indre*, dans une réserve d'interprétation portant sur la non-application du droit de se taire au référé-pénal environnemental.

Vous avez vous aussi fait preuve du même souci d'équilibre dans votre jurisprudence concernant les autorités administratives indépendantes (AAI) dotées de pouvoirs de sanction. On retrouve alors les tensions polaires évoquées précédemment : l'AAI dans sa fonction de régulation est en droit d'attendre une pleine coopération des entreprises du secteur qu'elle régule, sous peine d'ailleurs souvent de manquement d'entrave à l'enquête, tant la transparence du secteur est aux fondements de l'installation d'un régulateur. Mais elle peut dans certains cas être dotée de pouvoirs de sanction. Et alors vous étanchéifiez les garanties applicables à la phase pré-disciplinaire ou d'enquête de celles applicables à la phase de

[13] CC n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021
[14] CC n° 2021-975 QPC du 25 février 2022
[15] Décision n° 2011-191/94/95/96/97 QPC du 18 novembre 2011, dite garde à vue II, pt 20
[16] Cass. crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 21-81.277

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

sanction, en affirmant que les droits de la défense ne s'appliquent pas dans la phase pré-disciplinaire. Mais vous ménagez une soupape de porosité et donc de sécurité pour le cas où une « ***atteinte irrémédiable*** » aurait été causée à ce stade amont de la procédure. Ainsi dans votre décision *Société Alternative Leaders France*[17], s'agissant des enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans la phase préalable à la procédure de sanction, vous avez réservé l'hypothèse d'une « atteinte irrémédiable » aux droits de la défense, de nature à rejaillir sur la régularité de la décision de sanction. Vous avez retenu la même approche pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)[18], la Commission nationale informatique et libertés (CNIL)[19], la Commission de régulation de l'énergie (CRE)[20] et le Haut Conseil du commissariat aux comptes devenu la Haute autorité de l'audit[21]. Vous avez fait de même pour les sanctions des juridictions ordinales du contrôle technique[22], et pour les juridictions ordinales « de droit commun »[23].

Pour les décisions de sanction administrative, plus proches donc de la présente affaire, vous ne raisonnez pas en termes « d'atteinte irrémédiable », mais avez néanmoins déjà examiné les conditions dans lesquelles s'est déroulée une phase d'enquête antérieure au déclenchement de la procédure disciplinaire, soit en jugeant opérant à l'encontre de la décision de sanction le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête (CE, 26 juillet 2011, *M. X...*, n° 332807, 336077, T., pour un magistrat), soit, tout en le jugeant inopérant (CE 27 avril 1967, *GG...*, n° 63367, p. 179, pour une décision juridictionnelle), en examinant si une méconnaissance du principe d'impartialité par un organe d'inspection ou de contrôle est susceptible d'entacher d'illégalité interne la décision de sanction, le juge de l'excès de pouvoir devant alors rechercher si les faits reprochés à l'agent sont néanmoins établis au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier (CE 18 novembre 2022, *M. V...*, n° 457565, T.), étant entendu que depuis votre décision *G....* (Section, 16 juillet 2014, n° 355201), vous avez clarifié qu'il appartient au juge d'apprécier la légalité de la sanction au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait retenir dans le respect de son obligation de loyauté à l'égard de l'agent.

---

[17] CE, 6/1 ssr, 15 mai 2013, n° 356054, T. pp 453-597-742
[18] CE, 9/10 ssr, 15 décembre 2014, Banque populaire Côte d'Azur, n° 366640, T. pp. 534-664-848 sur un autre point, non explicite
[19] CE, 10/9 ssr, 18 novembre 2015, Société PS Consulting, n° 371196
[20] CE, 9/10 chr, 18 juin 2021, Sté Vitol, n° 425988, T.
[21] CE, 6/5 chr, 18 décembre 2023, T..., n° 451785, T.
[22] CE, 4/1 chr, 14 janvier 2021, M. AA…, n° 442985, 445397, T., dans la continuité de décisions plus anciennes telles que CE, 27 avril 1967, GG…, n° 63367, au Rec., p. 179
[23] CE, 6/5, 12 novembre 2020, Z…, n° 428931, T. p à propos d'une commission de déontologie de la chambre régionale de discipline ayant examiné les faits avant la juridiction ordinale des architectes

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

Si vous souhaitez vous inscrire dans cette veine de jurisprudence et admettre **un principe d'étanchéité, sans innocuité**, de la phase antérieure aux poursuites, il vous reste à déterminer l'outil adéquat pour l'appliquer au droit de se taire: recours à la notion, comme soupape de porosité, de l'« atteinte irrémédiable », ou bien à celle, plus englobante, de l'obligation de loyauté de l'administration, qui ne pourrait, sauf à faire revêtir à son interrogatoire le caractère d'un détournement de procédure[24], la conduire à questionner un agent sur des faits qui lui sont reprochés alors qu'elle est d'ores et déjà convaincue qu'elle utilisera ses propos dans le cadre ultérieur de poursuites disciplinaires.

Nous craignons que la première de ces notions, qui n'a d'ailleurs connu aucune application positive à ce jour, ne soit guère opérationnelle s'agissant du droit de se taire. L'expression « atteinte irrémédiable » désigne, comme le résumait O. Fuchs dans ses conclusions sous l'affaire *Z…* préc., « *quelque chose (…) qui ne peut être redressé par le simple exercice de la procédure juridictionnelle postérieure ou qui lui porte intrinsèquement atteinte* » ; mais en l'absence de règles d'exclusion en droit administratif, équivalentes aux règles de nullité en droit pénal (qui conduisent la chambre de l'instruction par exemple à « canceller » des actes ou pièces de la procédure[25]), il ne sera jamais possible d'effacer une parole, dans les écrits ou dans les mémoires, une fois qu'elle aura été prononcée : l'atteinte sera toujours irrémédiable, et la méconnaissance du droit au silence, si vous deviez la regarder comme un vice entachant la procédure de sanction dès ce stade amont, serait un « vice indélébile », par opposition aux « vices susceptibles d'être lavés par le temps de la procédure », pour reprendre une expression employée en doctrine[26], comme l'est par exemple le défaut de contradictoire[27]. Retenir cette notion risquerait donc de vous conduire à perméabiliser grandement une frontière que vous souhaitiez garder étanche.

---

[24] Cette notion est bien connue de votre jurisprudence, définie comme le « *procédé par lequel l'administration, dissimulant le contenu réel d'un acte sous une fausse apparence, recourt à une procédure prévue par la loi à des fins autres que celle qu'elle poursuit, afin d'éluder certaines formalités ou de supprimer certaines garanties* » (GAJA 4.4, voir pour des applications, Sect, 21 février 1947, Guillemet, Rec. p66 ; Ass, 24 juin 1960 Frampar, Rec. p412).

[25] Article 174 du code de procédure pénale

[26] A. Lubrani in « Miranda au pays des droits de l'homme, Droit au silence et auto incrimination en droit administratif », AJDA 2022.727

[27] V. aussi l'opinion partiellement dissidente des juges Sajo et Laffranque sous l'arrêt *Ibrahim et autres c/ Royaume-Uni* de la CEDH (13 sept. 2016, n° 50541/08) : « *dans certains cas [...], il n'y a aucun moyen de s'opposer à la déclaration auto-incriminante initiale [...] Nous sommes là au cœur de la condamnation car il est impossible d'en effacer les conséquences à un stade ultérieur (sauf application d'une règle d'exclusion)* ».

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

Nous vous inviterons donc à privilégier la loyauté de la procédure, c'est-à-dire à se concentrer sur le risque bien particulier, et sans doute d'occurrence assez rare, d'un détournement de la procédure pré-disciplinaire, c'est-à-dire l'hypothèse dans laquelle une phase pré-disciplinaire est mobilisée, allongée précisément pour contourner l'obligation de notification du droit de se taire dans la phase disciplinaire, pour obtenir que le mis en cause, en confiance, établisse lui-même l'exactitude matérielle des faits qui seront qualifiés par la suite avant d'être sanctionnés. Une telle situation est notamment susceptible de se produire lorsque, eu égard à l'ensemble des éléments dont disposait l'administration, il apparaissait d'ores et déjà certain qu'une procédure disciplinaire serait engagée et que l'enquête a été diligentée aux seules fins de recueillir, dans un cadre dépourvu de l'ensemble des garanties de la procédure disciplinaire, des propos de nature à fonder de manière déterminante la sanction ultérieurement prononcée.

4. Voilà pour le cas général. Nous nous sommes néanmoins posé la question de savoir, pour en revenir au dossier qui nous occupe, si les **particularités de la procédure disciplinaire applicable aux magistrats** de l'ordre judiciaire ne devaient pas vous conduire à nuancer quelque peu cette conclusion « d'étanchéité sauf déloyauté » s'agissant des enquêtes diligentées par l'Inspection générale de la justice sur la manière de servir des magistrats.

Expliquons-nous. Vous savez, pour avoir eu à connaître de la légalité du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice[28] (Section, 23 mars 2018, *Syndicat Force Ouvrière Magistrats et a.*, n° 406066 et a., concl. L. Dutheillet de Lamothe, RFDA, 2018, p. 509), que les inspections qu'elles réalisent peuvent porter tant sur le contrôle du fonctionnement d'une ou plusieurs juridictions que sur la manière de servir d'un magistrat particulier. Si vous avez alors admis que le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 64 de la Constitution, qui garantissent l'indépendance de l'autorité judiciaire, n'interdisaient pas la création d'un tel organe auprès du ministre de la justice, sous les conditions que vous avez énumérées et jugé remplies par le décret, sauf en ce qui concerne l'inclusion dans son champ d'application de la Cour de cassation, c'est au regard de « l'ambivalence constitutive », pour reprendre l'expression de notre collègue Louis Dutheillet de Lamothe, du pouvoir exécutif à l'égard de l'indépendance de l'autorité judiciaire, qui doit tout à la fois la respecter et la garantir, puisqu'il dote et gère juridictions et magistrats. Ce qui a joué un rôle déterminant dans votre raisonnement s'agissant en particulier du pouvoir d'enquête de l'Inspection sur le comportement professionnel ou personnel des magistrats, qui

[28] Qui a fusionné dans une seule inspection les services de l'inspecteur des services judiciaires avec les inspections des services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse.

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

constitue une singularité française, c'est le pouvoir dévolu au ministre de la justice d'engager la procédure disciplinaire contre un magistrat[29]. Pour le dire autrement et citer encore Louis Dutheillet de Lamothe, la faculté pour l'inspection de conduire une enquête administrative sur le comportement d'un magistrat « *qui, en pratique, constitue une enquête pré-disciplinaire (…) est la conséquence logique du fait que le statut organique confie au garde des Sceaux la tâche d'engager les procédures disciplinaires nécessaires.* ». Si l'enquête administrative menée par l'IGJ est « pré-disciplinaire », ce n'est donc pas seulement parce qu'elle précède l'engagement des poursuites, mais aussi, et surtout, parce qu'elle le prépare[30] : elle a notamment pour objet de nourrir le dossier disciplinaire[31], lorsque le garde des sceaux est saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites (art. 50 et 58-1 de l'ordonnance statutaire), et à cet égard, l'enquête administrative ne constitue pas le simple prolongement, ou une modalité d'exercice parmi d'autres, du pouvoir hiérarchique, puisque le garde des sceaux ne détient pas un tel pouvoir à l'égard des magistrats du siège et que les termes du décret créant l'inspection ne diffèrent pas selon que l'enquête vise un magistrat du siège ou du parquet.

En sens inverse, toutefois, nous relevons le commentaire officiel déjà cité de la décision n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024, rendue précisément à propos des dispositions applicables aux magistrats du siège, et votre propre décision du 23 mars 2018, qui, pour écarter le moyen tiré de l'inconstitutionnalité du décret, s'appuie notamment sur la circonstance « *que les enquêtes conduites par l'inspection générale de la justice sont, par elles-mêmes, sans effet sur les droits et prérogatives des magistrats qu'elles concernent (…) et que d'éventuelles sanctions disciplinaires ne peuvent être prises, s'agissant des magistrats du siège, que par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour ces magistrats et, s'agissant des magistrats du parquet, après l'avis de la formation de ce Conseil compétente à leur égard* » : si les enquêtes sur le comportement des magistrats sont entourées de garanties, rappelées par votre décision[32], l'engagement des poursuites ne constitue pas seulement un marqueur temporel, mais conduit aussi à placer le magistrat concerné dans une situation

[29] Qu'il tient de l'article 50-1 de l'ordonnance statutaire s'agissant des magistrats du siège, et de l'article 63 s'agissant des magistrats du parquet, vis-à-vis desquels il exerce lui-même la discipline puisqu'il lui revient de prendre la décision de sanction après avis motivé de la formation compétente du CSM (art. 66)

[30] V. pour des exemples dans votre jurisprudence de la mention de telles enquêtes administratives ayant nourri la motivation du déclenchement des poursuites à l'encontre de magistrats du siège : CE 26 décembre 2012, *J...* n° 346320 et *GA…* n° 348148

[31] Il était notamment demandé à la mission « de déterminer si les comportements de l'intéressé que l'enquête révèlerait, sont susceptibles de constituer des fautes disciplinaires »

[32] Et notamment celle selon laquelle l'inspection générale de la justice ne saurait recevoir d'instruction du garde des sceaux « sur la manière de conduire une inspection une fois que celle-ci a été diligentée »

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

juridique différente, d'une certaine façon plus vulnérable et plus précaire, dans la mesure où la perspective de la sanction, si elle demeure éventuelle, ne peut plus être ignorée, mais aussi et surtout, et c'est un corollaire, entourée de davantage de garanties. Dans ces conditions, il nous semble finalement logique, eu égard à la substance du droit de se taire, dont l'origine de protection contre la coercition a été retracée avec brio dans les conclusions de Jean-François de Montgolfier, que sa notification ne s'impose qu'une fois les poursuites engagées, c'est-à-dire ensemble avec les autres garanties supplémentaires pour les magistrats, comme le droit à la communication du dossier (art. 51 et art. 63-3) dont la saisine du Conseil supérieur de la magistrature est accompagnée[33].

Mais il est des enquêtes administratives qui ne sont diligentées qu'après l'engagement des poursuites, comme dans le cas de M. O... : l'Inspection et le CSM ont en effet été saisis le même jour, le 28 avril 2022. Cela tient peut-être au fait que, selon ce qui ressort de la décision attaquée, les faits motivant les poursuites disciplinaires ont initialement été dénoncés à la direction des services judiciaires par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, en juin 2019, quelques jours après que lui-même en ait été informé[34]. Or l'ordonnance statutaire prévoit que lorsque ce sont les chefs de cour[35] qui saisissent le CSM[36], le garde des sceaux, qui reçoit copie des pièces, peut demander une enquête à l'IGJ : dans cette hypothèse, l'enquête administrative a toujours lieu après l'engagement des poursuites.

En outre, depuis la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire[37], « lorsque la technicité des actes

---

[33] Nous réservons la question de savoir si le droit de se taire doit s'appliquer à la procédure d'avertissement prévue à l'article 44 de l'ordonnance statutaire, qui donne lieu à communication du dossier (24 juillet 1987, *VP*..., n° 53676, au Rec., puis loi n° 2016-1090 du 8 août 2016) et à l'assistance d'un conseil dès la convocation du magistrat concerné à un entretien préalable. Cette procédure échappe à l'action disciplinaire (et ne nécessite pas l'intervention du CSM) mais est une mesure prise en considération de la personne qui revêt, selon les termes de S. Coester dans ses conclusions sous votre décision *MP*... (28 avril 2017, n° 390598) « un caractère disciplinaire même si ce n'est pas une sanction », par référence au raisonnement tenu dans votre décision d'Assemblée *DD*... (16 janvier 1976, n° 92731).

[34] Durant cette période de trois ans, dont la durée inhabituelle peut surprendre, entre la dénonciation des faits et la saisine concomitante de l'IGJ et du CSM, M. O... était placé en congé longue maladie

[35] Premiers présidents de cour d'appel ou présidents de tribunal supérieur d'appel : art. 50-2 ; procureurs généraux près les cours d'appel ou procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel : art. 63

[36] Pouvoir qu'ils détiennent depuis la loi n° 2001-539 du 25 juin 2001

[37] Qui a partiellement suivi sur ce point un avis du CSM au Président de la République remis le 24 septembre 2021, proposant d'étendre encore les facultés de saisine de l'Inspection à d'autres instances que le garde des Sceaux aux fins d'engagement d'une enquête administrative après qu'il soit lui-même saisi, soit par les chefs de cour (qui pourraient ainsi saisir directement l'IGJ), soit par la commission d'admission des requêtes, créée au sein de chacune des deux formations compétentes du CSM pour examiner les plaintes des justiciables, qui

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

d'enquête le justifie », la commission d'admission des requêtes[38] (art. 50-3 et art. 63) mais aussi le rapporteur désigné par le CSM parmi ses membres (art. 52 auquel renvoie l'art. 63-3) peuvent également solliciter du garde des sceaux que soit diligentée une enquête administrative. Si dans la première de ces deux hypothèses, qui ne sera pas la plus courante[39], l'enquête demeure préalable à l'engagement des poursuites, sans doute matérialisé par le renvoi de l'examen de la plainte du justiciable au conseil de discipline pour les magistrats du siège, ou à la formation du CSM compétente pour la discipline des magistrats du parquet, dans le second cas, l'enquête administrative vient en appui de l'enquête disciplinaire menée par le rapporteur.

Les hypothèses dans lesquelles l'enquête administrative ne serait plus *pré*-disciplinaire mais interviendrait bien *dans le cadre* de l'action disciplinaire – serait, pour le dire autrement, « **para-disciplinaire** », ou disciplinaire à raison de son objet, si l'on devait retenir un critère fonctionnel - sont donc appelées à se multiplier, à tout le moins pour les magistrats, et il convient d'en tirer les conséquences en précisant dans votre décision que dans le cas où une procédure disciplinaire est déjà engagée à l'encontre du magistrat intéressé, et qu'il est *ensuite* entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit en vue d'éclairer l'autorité disciplinaire, il appartient aux enquêteurs de l'informer de son droit de se taire, puisque l'enquête administrative est alors couverte par le champ d'application temporel de ce droit dont le point de départ est l'engagement des poursuites. Cette approche est cohérente

---

peuvent aussi saisir le CSM du comportement d'un magistrat depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 (avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution et art. 50-3 et 63 de l'ordonnance statutaire), soit encore par le rapporteur qu'il désigne pour mener l'enquête disciplinaire afin qu'il puisse se faire assister dans ses investigations par les inspecteurs des services judiciaires si aucune enquête préliminaire n'a été diligentée

[38] Dans leur rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023, l'article 50-3 et l'article 63 de l'ordonnance statutaire prévoient aussi que la commission d'admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause par le justiciable, après avoir déclaré recevable la plainte de ce dernier ; mais avant de renvoyer l'examen de la plainte au conseil de discipline ou à la formation compétente pour la discipline des magistrats du parquet lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire. La question, que nous réservons, peut se poser de savoir si cette audition du magistrat par la commission d'admission des requêtes, postérieure à la saisine du CSM mais préalable à l'engagement des poursuites qui se matérialiserait par le renvoi de l'examen de la plainte à l'instance disciplinaire compétente, doit être précédée de la notification du droit de se taire.

[39] Le CSM reçoit chaque année entre 1200 et 1300 plaintes, qui donnent lieu à l'ouverture de 300 à 350 dossiers, mais depuis l'instauration de cette procédure de saisine directe du CSM par le justiciable, seuls huit dossiers ont donné lieu à un renvoi devant la formation disciplinaire et seul un a abouti à une condamnation. Dans son communiqué du 13 juin 2024 sur cette décision de condamnation, le CSM dit avoir regretté par le passé de ne pas disposer de pouvoirs d'investigation, la loi organique faisant reposer sur le justiciable la preuve des manquements, et se satisfaire de ce que le Conseil pourra désormais saisir le ministère de la justice aux fins d'enquête administrative conduite par l'IGJ lorsque cela lui semble nécessaire au regard des faits dénoncés.

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

avec la réserve d'interprétation récemment opérée par le Conseil constitutionnel dans sa décision préc. sur le référé-pénal environnemental : en écartant l'application du droit de se taire à cette procédure, distincte de la procédure pénale, il a réservé l'hypothèse d'une procédure parallèle, c'est-à-dire celle dans laquelle la personne concernée serait déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue.

Et nous pensons qu'en matière disciplinaire, c'est bien une approche temporelle qu'il faut suivre, en distinguant entre la phase préalable et la phase postérieure à l'engagement des poursuites, et non une approche substantielle qui s'attacherait aux faits les ayant motivés, puisque les autorités disciplinaires, à la différence du juge pénal, sont saisies « in personam » et non pas « in rem » : elles peuvent connaître de l'ensemble du comportement de la personne poursuivie et ne sont pas tenues de limiter leur examen aux seuls faits qui ont initialement été portés à leur connaissance[40]. Le cas d'espèce l'illustre d'ailleurs bien puisque l'enquête administrative a fait apparaître d'autres manquements, tirés des insuffisances professionnelles, que ceux liés à l'enquête pénale dirigée en secret, initialement reprochés à M. O... par le procureur de la République et le procureur général, et qui étaient repris dans la dépêche par laquelle le garde des sceaux a saisi la formation du CSM compétente en matière de discipline des magistrats du parquet ; de sorte que le ministre a procédé à une saisine complémentaire après avoir reçu le rapport de l'Inspection pour abandonner certains griefs et en ajouter de nouveaux. Il serait d'ailleurs artificiel de notifier à l'intéressé le droit de se taire lorsqu'il est entendu par l'inspection pour les faits à l'origine de la saisine de l'autorité disciplinaire, mais pas sur d'autres faits révélés par les investigations et qui sont susceptibles, soit d'étayer les griefs initiaux (auquel cas une saisine complémentaire n'est même pas nécessaire[41]), soit d'en fonder de nouveaux.

Si vous nous suivez, vous jugerez donc qu'il incombait aux inspecteurs de l'IGJ de notifier à M. O... son droit de se taire lorsqu'ils l'ont auditionné pendant deux jours et demi, en septembre 2022, postérieurement à l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre. Nous reviendrons sur les conséquences à tirer de ce défaut de notification.

---

[40] Section, 8 juin 1956, Dardenne, p. 239 ; Section, 16 mai 1958, Sté de courtage et d'affrètement fluvial, p. 276 ; pour le CSM : 26 octobre 2005, JJ…, n° 278224, aux T, *MP*..., n° 489324 (séance du 22 novembre 2024, décision non encore lue)

[41] Le rapporteur, non plus que le Conseil, ne peut pas modifier le champ de la saisine (pour les magistrats du siège : CE Section 6 novembre 2002, *W*..., n° 225341, p. 385 ; et pour les magistrats du parquet, conclusions du Président Lamy sous CE, 12 janvier 2004, *CA*..., n° 248702, aux T.).

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

5. Une fois les poursuites déclenchées, et en application de l'article 63-3 de l'ordonnance statutaire, s'ouvre une phase d'instruction à l'orée de laquelle le président de la formation de discipline compétente pour les magistrats du parquet désigne l'un de ses membres en qualité de rapporteur. La rapporteure désignée pour instruire la procédure disciplinaire à l'encontre de M. O... a procédé à son audition le 21 avril 2023, sur le fondement des dispositions (art. 52 auquel renvoie l'art. 63-3) déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2024 et qui prévoient que « *le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause* »[42]. Néanmoins, comme nous vous l'avons indiqué, il ressort du PV de l'audition que dans la mesure où à cette date, le CSM, en sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège, vous avait renvoyé une QPC[43] interrogeant la conformité de ces dispositions au regard des exigences découlant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, la rapporteure a indiqué « à toutes fins utiles » à M. O..., par une formule inspirée du code de procédure pénale[44] dont vous a entretenu Jean-François de Montgolfier que, « dans l'attente de la réponse qui serait donnée aux QPC (…) relatives à l'absence de notification du droit au silence au magistrat mis en cause disciplinairement, tant lors de son audition par le rapporteur que lors de l'audience au fond », « il [pouvait] faire des observations, répondre à [ses] questions ou se taire. » M. O... a alors répliqué qu'il souhaitait « répondre bien évidemment à [ses] questions ».

La question qui peut se poser est de savoir si l'**information était suffisante**, dans la mesure où, d'une part, elle n'a pas été réitérée au cours des phases ultérieures de la procédure, et où d'autre part, elle n'a été donnée qu'oralement, au début de l'audition par la rapporteure, et n'a pas été signifiée par écrit, par exemple dans la convocation de M. O... à cette audition. Eu égard à ce que nous venons de vous dire sur l'inclusion dans le champ de l'obligation de notification des enquêtes administratives diligentées après le déclenchement des poursuites, vous pourriez aussi vous interroger sur le point de savoir s'il ne convient pas que l'information sur cette obligation soit délivrée dès ce moment, afin de couvrir non seulement toutes les étapes formelles de la procédure disciplinaire, mais aussi toutes les opportunités

[42] Ces dispositions ont été abrogées par la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ce qui explique que le Conseil constitutionnel n'ait pas reporté dans le temps les effets de sa déclaration d'inconstitutionnalité, à la différence des dispositions de l'article 56 également censurées, dont l'abrogation ne prendra effet qu'au 1er janvier 2025. Mais les mots « le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause » demeurent dans les dispositions de l'article 52 en vigueur issues de la loi organique du 20 novembre 2023.

[43] Non renvoyée (CE 23 juin 2023 *AA*..., n° 473249), la décision n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 faisant suite à une décision de renvoi de votre part (CE 19 avril 2024, n° 491226) à la lumière de la circonstance de droit nouvelle que constituait l'interprétation donnée à l'article 9 de la Déclaration de 1789 par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023.

[44] Art. 61-1

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

données à l'intéressé de s'exprimer à compter de l'engagement des poursuites, que ces opportunités résultent des textes, de sollicitations expresses non prévues par les textes, ou bien encore d'une initiative propre de la personne mise en cause dont elle pourrait ensuite imputer la responsabilité à l'autorité disciplinaire en faisant valoir qu'elle avait été mal informée. Vous pourriez enfin vous demander si l'obligation d'information doit être restreinte aux phases d'oralité, ou bien si elle s'applique également au recueil d'observations écrites[45].

S'agissant de cette dernière question, il nous semble qu'elle peut être réservée: dans ses quatre décisions relatives aux sanctions disciplinaires[46], le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur des phases d'oralité de la procédure respectivement applicable aux notaires, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux magistrats de chambres régionales des comptes, et si, dans le champ de la procédure pénale, il a censuré des dispositions relatives à une procédure écrite, applicable en matière de délits de presse[47], il s'agissait d'une procédure particulière de mise en examen, dont il est difficile de tirer des conclusions définitives pour la répression administrative. A ce stade, il nous semble donc plus conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel de vous borner à juger qu'il en découle que le professionnel concerné doit être informé de son droit de se taire avant d'être « entendu » sur les manquements qui lui sont reprochés, terme auquel vous pourriez éventuellement adjoindre celui « d'interrogé », si vous souhaitiez couvrir l'hypothèse d'une audition écrite, c'est-à-dire d'un questionnaire précis adressé à la personne concerné, mais sans aller jusqu'à y intégrer toutes les possibilités d'observations écrites que la personne concernée aurait la possibilité de formuler, sans y être obligée.

Quant aux autres questions, deux approches nous semblent possibles pour y répondre : l'une, qui est peut-être celle qui est attendue de vous par les administrations, consisterait à donner un mode d'emploi détaillé de la notification du droit se taire ; l'autre, que nous vous conseillons, au risque de décevoir, consiste à s'en tenir à ce qui découle de la jurisprudence du Conseil

[45] A supposer en effet, par exemple – mais c'est une question que nous réservons - que l'examen des plaintes de justiciables par la commission d'admission des requêtes, postérieure à la saisine du CSM par ces derniers, mais préalable à l'engagement des poursuites qui se matérialiserait par le renvoi de l'examen de la plainte à l'instance disciplinaire compétente par la commission d'admission, entre dans le champ de l'obligation d'information sur le droit de taire, il faudrait alors se poser la question de savoir si les observations du magistrat mis en cause que le chef de cour invite à lui adresser (formulation qui laisse entendre que ces observations peuvent être écrites) seraient couvertes par une telle obligation.

[46] Décisions n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 (notaires), 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 (magistrats du siège), 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 (fonctionnaires) et 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024 (magistrats de chambres régionales des comptes)

[47] Décision n° 2024-1089 QPC

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

constitutionnel[48], et confier au juge de la sanction l'appréciation souveraine du caractère suffisant de la notification.

S'agissant d'abord d'une éventuelle obligation de réitération de l'information, on peut certes noter que les termes de ses décisions relatives aux procédures disciplinaires applicables aux magistrats du siège et aux magistrats de chambres régionales des comptes distinguent entre l'audition par le rapporteur et la comparution devant le conseil de discipline[49]. Cela plaiderait dans le sens d'une obligation de réitération de l'information à chaque étape de la procédure disciplinaire, tout du moins juridictionnelle, instruction puis audience, voire, selon une approche organique, à chaque fois que la personne mise en cause comparaît devant une autorité différente. Mais on pourrait aussi faire valoir que cette distinction faite par le Conseil constitutionnel entre les deux phases de la procédure présente un caractère conservatoire, dans l'attente d'une modification législative, et ne préjuge pas de la constitutionnalité d'une information donnée « une fois pour toutes » au début de la procédure, pourvu qu'il résulte clairement de sa formulation qu'elle a vocation à couvrir toutes ses étapes. A cet égard, et si vous souhaitiez vous permettre une analogie avec la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, vous pourriez relever qu'il en ressort, ainsi que l'a formulé son premier avocat général[50], « *qu'il n'y a pas lieu de réitérer la notification du droit de se taire en cas de succession d'actes s'inscrivant dans un processus unique* » ; or l'instance disciplinaire est unique, quand bien même elle ferait intervenir des autorités distinctes, comme le rapporteur, puis la formation compétente du CSM, puis encore le garde des sceaux s'agissant des magistrats du parquet, et les autorités de poursuite puis de jugement en matière juridictionnelle. A dire vrai, et si l'on retient une approche pragmatique, il nous semble que les échos d'un avertissement donné en amont, s'il est formulé en des termes clairs, devraient en toute logique retentir aux oreilles de la personne mise en cause jusqu'à l'issue de la procédure, sans qu'il soit besoin de le lui répéter.

---

[48] V. Pierre-Olivier Rigaudeau, « La pénalisation de la répression administrative et l'affirmation du droit au silence », AJDA 2024.1051 – « plusieurs modalités sont envisageables selon la procédure de sanction concernée ».

[49] en jugeant qu'en ne prévoyant pas que le magistrat poursuivi doit être informé de son droit de se taire lors de son audition ainsi que lors de sa comparution, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789, et en exigeant, tout en reportant dans le temps les effets de sa déclaration d'inconstitutionnalité, que l'information soit pour l'avenir donnée à la fois par le rapporteur et le conseil supérieur de discipline des magistrats de CRC jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou la date de l'abrogation prononcée

[50] Avis de F. Desportes sur l'affaire Ass. plén. 28 juillet 2023, n° 21-86.418 et a., publié au Bulletin

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

Il en va de même de la question de savoir si l'avertissement doit être donné par écrit ou seulement oralement : une indication écrite, dans le courrier d'information à la personne mise en cause de l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre, par lequel elle est également informée de son droit à communication du dossier et à l'assistance d'un conseil ; ou dont il serait certain qu'elle pourrait être reprise par écrit, par exemple dans un PV d'audition, pourrait être jugée plus sécurisante pour l'administration ; mais ces considérations d'opportunité lui appartiennent et nous ne voyons pas de prise, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, pour la contraindre à cet égard.

Nous vous invitons donc à retenir une approche pragmatique, peu teintée de formalisme, et qui n'apparaîtra qu'implicitement dans votre décision puisqu'elle vous conduira à apprécier le caractère suffisant de l'information délivrée dans les circonstances de l'espèce.

S'agissant de M. O..., dans les termes dans lesquels la notification de son droit de se taire a été opérée, faisant mention des QPC portant sur les deux dispositions finalement déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel, relatives à l'audition par le rapporteur (l'art. 63-3 renvoyant à l'art. 52) d'une part, à l'audience au fond, c'est-à-dire à la comparution devant la formation compétente du CSM (l'art. 64 renvoyant à l'art. 56) d'autre part, mais aussi parce qu'elle s'adressait à un magistrat dont les qualifications le mettaient à même de comprendre la portée de ce qui lui était ainsi signifié, il nous semble que vous pourrez juger que, dans les circonstances de l'espèce, la notification valait pour ces deux étapes de la procédure disciplinaire, quand bien même elle n'aurait pas été réitérée lors de sa comparution devant le CSM. Nous serions même d'avis qu'elle devait être comprise comme valant pour l'ensemble de la procédure, jusqu'à son issue, c'est-à-dire la décision prise par le garde des Sceaux, si une autre audition avait eu lieu ultérieurement sur le fondement des dispositions de l'article 66 de l'ordonnance statutaire qui ont jusqu'à présent échappé à la censure constitutionnelle, et qui prévoient que lorsque le garde des sceaux entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du Conseil supérieur, cette dernière émet alors un nouvel avis « après avoir entendu les observations du magistrat intéressé ». Aucune audition par le garde des Sceaux lui-même n'est en revanche prévue par les dispositions applicables de l'ordonnance statutaire[51] ; et si, eu égard à l'autorité qu'il exerce sur les magistrats du parquet[52], et à la circonstance qu'il ne saurait renoncer à son

[51] Dont le silence sur ce point nous semble significatif compte tenu par ailleurs de son extrême précision en ce qui concerne la procédure disciplinaire, reflet des garanties d'indépendance dont bénéficient les magistrats. V. les conclusions de la Présidente Grévisse sur votre décision d'Assemblée *Sieur DD*... (16 janvier 1976) à propos des conditions de notation des magistrats.

[52] Qui découle de l'article 5 de cette même ordonnance et a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

propre pouvoir d'appréciation[53], l'hypothèse d'une telle audition ne nous semble pas non plus exclue, M. O... ne soutient pas en avoir été l'objet. Son moyen pourra donc être écarté, en tant qu'il porte sur la procédure disciplinaire.

6. Demeure la question de savoir quelles conséquences il convient de tirer de la méconnaissance de l'obligation des inspecteurs de l'IGJ de notifier à M. O... son droit de se taire. Cette question nous semble d'ailleurs devoir être traitée de manière identique, que la notification eût dû, comme dans le cas particulier de M. O..., être opérée par les inspecteurs, ou bien seulement dans la phase disciplinaire, de sorte que nous pouvons vous entretenir d'abord du cas général, avant d'en venir au cas d'espèce.

Une première lecture de l'obligation procédurale d'information sur le droit de se taire dégagée par le Conseil constitutionnel consisterait à la voir comme une garantie en elle-même, dont la méconnaissance entraînerait mécaniquement l'irrégularité de la sanction prononcée. Autrement dit, l'obligation d'information serait prescrite à peine de nullité de la procédure, aucune neutralisation de l'irrégularité tirée de sa méconnaissance n'étant possible.

Mais selon nous, deux séries de raisons s'opposent à une lecture aussi radicale :

(i) **Une raison d'opportunité et d'équilibre** : la radicalité conduirait nécessairement à annuler des sanctions pour lesquelles la méconnaissance de cette obligation formelle n'aurait pas eu d'incidence pour la personne poursuivie, par exemple si elle a d'elle-même gardé le silence ou s'il elle n'a rien confirmé des faits. La Cour de cassation, même dans les cas où elle estime que le défaut de notification fait intrinsèquement grief au requérant, par exemple les comparutions à l'audience, n'annule pas la décision lorsque le prévenu n'a pas du tout pris la parole[54] ; ou lorsqu'il l'a prise, mais seulement pour s'exprimer sur des éléments sans rapports avec les faits reprochés[55]. L'automaticité ici pourrait ainsi conduire des agents écartés du service pour des faits graves à réintégrer celui-ci, l'administration n'ayant pas toujours la possibilité de reprendre la procédure pour aboutir au prononcé d'une nouvelle sanction.

(ii) Une **raison de cohérence** : il y a longtemps déjà que vous avez engagé votre jurisprudence dans le sens d'une neutralisation possible de certains vices de procédure, avec

---

constitutionnel dans sa décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017

[53] Section, 20 juin 2003, *S...*, n° 248242

[54] Ass. plén., 4 juin 2021, pourvoi n° 21-81.656, à propos d'une audition correctionnelle

[55] Crim., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-85.228 pour un prévenu s'étant seulement exprimé sur la question de la composition de la juridiction qui pouvait, à la demande de l'intéressé, être collégiale plutôt qu'à juge unique

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

la théorie des vices non substantiels née avec votre décision d'Assemblée *Association des amis de l'Abbaye de Fontevraud* (7 mars 1975, n° 89011, 89128, Rec. p179), et formalisée par la jurisprudence *DA…* (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, *M. DA… et autres*, n° 335033, Rec. p649), qui conduit à ne pas tirer des conséquences automatiques de vices procéduraux, mais à rechercher s'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise[56] ou s'ils ont privé l'intéressé d'une garantie.

Nous nous permettons ici de faire une parenthèse et de vous indiquer que si vous deviez vous pencher sur une sanction infligée à un magistrat du siège par le CSM siégeant en conseil de discipline, vous seriez alors juges de cassation d'une décision juridictionnelle, de sorte que les conséquences à tirer d'un défaut de notification seraient celles que vous a expliquées J.-F. de Montgolfier, mais qui ont une inspiration « neutralisatrice » commune (CE 7 juillet 2004, *Communauté d'agglomération Val de Garonne*, n° 256398, T. p831).

La méconnaissance de la notification du droit de se taire est-elle « danthonysable » ? Pour répondre à cette question, il faut vous attacher à définir plus précisément la portée, non seulement de l'obligation d'information qui pèse sur l'autorité disciplinaire (le cas échéant administrative), mais aussi et surtout de la garantie qui en ressort pour la personne interrogée. Peut-être faut-il en revenir à ce stade aux racines latines du *ius tacendi*, ou plus exactement de l'adage *nemo tenetur se detegere* : nul ne devrait être obligé de se dévoiler, de révéler ce qui, s'il n'avait été contraint de parler, eût jusqu'alors été resté caché. Bien davantage qu'une obligation procédurale dont la méconnaissance serait automatiquement sanctionnée, ce droit confère donc une garantie substantielle, de protection de la personne contre l'utilisation qui pourrait être faite de propos obtenus sous la contrainte, cette contrainte devant être entendue dans l'acception qu'en a donnée le Conseil constitutionnel comme naissant de l'absence d'information sur le droit de se taire. La personne entendue n'est donc pas privée d'une garantie du seul fait que cette obligation d'information a été méconnue ; mais du fait de l'utilisation qui pourrait être faite des propos tenus alors qu'elle l'a été.

Dans ce sens, la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui adopte des solutions rigoureuses pour le contentieux des nullités en cours de procédure, juge en revanche, lorsqu'elle est saisie de pourvois dirigés contre des décisions de condamnation ou des arrêts

[56] Vous avez d'ailleurs déjà pu procéder comme juge d'une décision de sanction d'un magistrat du parquet à un exercice analogue consistant en l'occurrence à écarter des faits matériellement inexacts, et à rechercher si le garde des sceaux aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres faits reprochés à l'intéressé (CE 26 octobre 2005 *JJ…* préc.).

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

de mise en accusation, que le moyen de méconnaissance du droit de se taire doit être écarté, même si le gardé à vue n'avait pas reçu notification de ses droits ou n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, dès lors qu'elle est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable, la juridiction infligeant la peine ne s'est fondée « *ni exclusivement ni même essentiellement* » sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue sans bénéficier de ces garanties[57]. Et, par deux décisions du 11 juillet 2019[58], la Cour EDH a validé cette approche ; elle-même écarte une méconnaissance de l'article 6 de la Convention lorsqu'il n'est pas établi que l'utilisation, dans la procédure pénale, de déclarations faites[59] alors que les intéressés n'avaient pas été informés du droit de se taire, a eu un impact sur le verdict de culpabilité ou les peines prononcées (CEDH, *Corbet c/ France*, n° 7494/11, 7493/11 et 7989/11).

En retenant un raisonnement analogue, vous ne vous éloigneriez pas de vos élans récents. Vous avez notamment déjà fait application de la jurisprudence *DA…* à des décisions administratives de sanction en vous attachant, face à une garantie se présentant comme formelle et procédurale, à en redéfinir la teneur comme garantie de fond : ainsi pour la communication des pièces du dossier disciplinaire, vous regardez si le requérant n'a pas été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense ; pour l'audition séparée de témoins, vous vérifiez qu'il n'a pas été porté atteinte à la garantie qui s'attache à la sincérité des témoignages (CE, 20 juillet 2021, *Ministre de l'intérieur c/ M. B…*, n° 445843, 445845, T. ; et CE, Sect., 22 décembre 2023, *Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c./ M. VE…*, n° 462455, Rec.).

Pour nous résumer, il nous semble donc que l'irrégularité résultant du défaut d'information quant à l'existence du droit de se taire n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de son droit de se taire. De manière déterminante, parce que toutes les autres configurations envisageables nous semblent devoir exclure une solution d'annulation. En effet, si rien n'est véritablement découvert, si les propos tenus ne dévoilent rien d'autre que ce qui était déjà

[57] Cf. pour l'assistance d'un avocat : Crim., 6 décembre 2011, pourvoi n° 11-80.326, Bull. crim. 2011, n° 247 ; Crim., 7 février 2012, pourvoi n° 11-83.676, Bull. crim. 2012, n° 37 ; Crim., 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-87.281, Bull. crim. 2012, n° 185). Cette ligne a été confirmée ensuite par de nombreux arrêts publiés au Bulletin.

[58] Olivieri c/France, 62313/12 ; Bloise c/France, 30828/13

[59] Devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en l'espèce

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

connu ou même seulement suspecté, mais qui peut être également confirmé par des éléments objectifs ou des témoignages présents au dossier, la garantie découlant du droit se taire dans l'acception que nous vous en avons proposée n'est pas méconnue.

Il ne s'agit pas seulement de conduire un exercice de « fiction rétrospective », pour reprendre une formule employée par Edouard Crépey dans ses conclusions sous la décision *PS Consulting* préc., en reconstituant les orientations prises par une instruction à partir du moment où la personne a parlé ; mais, de manière analogue à ce que vous avez jugé dans votre décision de Section *G...* préc., selon laquelle, face à des preuves obtenues par l'employeur en méconnaissance de son obligation de loyauté à l'égard de ses agents, il appartient au juge administratif, saisi de la sanction disciplinaire, d'en apprécier la légalité « *au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir* », ce qui implique pour le juge d'apprécier si le dossier disciplinaire tiendrait en l'« expurgeant » des preuves viciées, de se poser la question de savoir au vu de l'ensemble des pièces du dossier si, en faisant abstraction des déclarations éventuellement obtenues en méconnaissance de l'obligation d'information sur le droit de se taire, il eût été suffisant à fonder la sanction et par suite à faire échapper cette dernière à l'annulation: si la personne ne s'était pas du tout exprimée, ou bien s'était exprimée sur un tout autre sujet sans lien avec la réalité matérielle des faits reprochés, c'eût été naturellement suffisant ; si elle s'était exprimée sur les faits, sans s'auto-incriminer, c'est-à-dire sans y reconnaître une part de responsabilité, c'eût été suffisant ; si elle s'était auto-incriminée, mais que figurent au dossier d'autres éléments, par exemple des témoignages concordants ou des éléments de preuve objectifs (écrits, notamment), dont il apparaît qu'ils ont pesé, au moins à parts égales avec les révélations faites par l'intéressé, dans la motivation de la sanction, c'eût également, selon nous, été suffisant.

Et si la personne s'était auto-incriminée et que la sanction s'appuie sur ces déclarations davantage que sur d'autres éléments de preuve, ou bien si la motivation en fait exclusivement état, pour l'un au moins des manquements constatés, il appartiendra alors au juge de rechercher encore si la même sanction eût pu être prononcée en retenant uniquement les autres manquements, par un raisonnement « Dame Perrot » (Ass, 12 janvier 1968, 70951, Rec. p3) que vous avez pratiqué dès l'origine s'agissant de sanctions disciplinaires[60].

[60] CE, 2/4, 31 janvier 1968, BT…, n° 61022, T. p, CE, 21 février 1969, Ministre des Postes et Télécommunications c/ K…, n° 75274, Rec. p ; CE, 27 novembre 1996, Epoux WW…, n° 170209, CE, 3/8, 3 mai 2023, Ba c\département de Seine St-Denis, n° 438248, Rec. p

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

Pour en venir au cas de M. O..., quatre séries de considérations, qui portent pour trois d'entre elles sur les modalités suivant lesquelles les manquements ont été établis, et la dernière sur le choix de la sanction prononcée, nous conduisent à conclure qu'en l'espèce, les déclarations faites par M. O... aux inspecteurs de l'IGJ ne doivent pas être regardées comme une tache indélébile dans un dossier de preuves par ailleurs immaculé.

En premier lieu, s'agissant des manquements aux devoirs de loyauté, d'impartialité et de probité, l'élément déclencheur des poursuites[61] n'était pas une parole donnée, qu'elle soit celle de M. O..., sous forme d'auto-incrimination, ou de témoins, supérieurs hiérarchiques, collègues ou justiciables, que les auditions du magistrat auraient ensuite cherché à confirmer ou corroborer ; mais un fait objectif : l'appel d'un des mis en cause contre une de ses décisions, prises dans le cadre de l'enquête pénale qu'il avait jusqu'alors dirigée dans le plus grand secret, trois jours avant son départ de la juridiction pour congé longue maladie. De la même façon, lorsqu'il s'est agi d'étayer les soupçons, d'autres éléments de preuve ont surgi sans que le procureur de la République puis le procureur général, qui en ont tous deux fait rapport, n'aient interrogé M. O..., absent du fait de ce congé.

En deuxième lieu, si ce dernier, selon les termes du rapport de l'Inspection, « s'est livré sans difficulté » pendant l'enquête, « manifestant à plusieurs reprises son souhait de s'exprimer en tout franchise » et a admis « avoir manqué à certaines de ses obligations dans la conduite de l'affaire pénale et plus généralement dans son exercice professionnel », la mission a opéré son constat des manquements sur la base de faits constants, notamment l'absence d'enregistrement de la procédure pénale par M. O... qui a fait obstacle à ce que sa hiérarchie en prenne connaissance.

En troisième lieu, les témoignages portant sur ses insuffisances professionnelles, qui fondent le manquement à l'obligation de délicatesse et émanent tant de la hiérarchie que de collègues, sont nombreux et convergents, si bien que les propos tenus par M. O... devant l'inspection, par lesquels il a reconnu certaines difficultés tout en faisant valoir la particularité de sa situation personnelle, revêtent un caractère confirmatoire mais non déterminant.

---

[61] A contrario, v. le raisonnement tenu par la CEDH tel que résumé par A. Lubrani in « Miranda au pays des droits de l'homme, Droit au silence et auto incrimination en droit administratif », AJDA 2022.727 : « Si la mention, dans la décision finale de sanction, d'aveux auto-incriminants ne signifie pas nécessairement que ces derniers ont joué un rôle prépondérant sur la sanction infligée, il en va autrement lorsque ces propos sont utilisés non pas en bout de chaîne mais à l'aube de la procédure. » (CEDH 13 sept. 2016, n° 50541/08, Ibrahim et a. c/ Royaume-Uni)

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

Enfin, dans l'appréciation globale des pièces du dossier qui peut être celle du juge, il nous semble que si les inspecteurs de l'IGJ et la rapporteure du CSM après eux, en faisant leurs rapports, le CSM, en émettant son avis motivé, et le garde des sceaux, en prononçant la sanction, ont pris en compte des révélations faites par M. O..., c'était à décharge, pour tenir compte de son état de santé et de celui de ses enfants et qu'il n'avait, jusqu'à son placement en congé de longue maladie, jamais évoqué, par pudeur, discrétion, embarras, peut-être, en tout cas du fait d'une certaine idée des devoirs de son état[62]. Au regard de la gravité des faits reprochés, la sanction de déplacement d'office, deuxième après le blâme dans l'échelle des sanctions prévue par l'article 45 de l'ordonnance statutaire, apparaît contenir en elle-même la prise en compte de circonstances atténuantes dont le requérant avait pu faire état.

7. Mais c'est déjà se pencher sur le **bien-fondé de la sanction** que de vous faire part de cette appréciation. Pour ne pas être trop longue, nous vous dirons simplement à ce sujet, qui fait l'objet du second moyen de la requête, que tant dans son principe que dans son quantum, sur lesquels vous exercez un contrôle normal[63] s'agissant d'un magistrat du parquet, comme pour les autres agents publics[64], le choix de la sanction infligée par le ministre à M. O... n'est pas disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.

Nous ne reviendrons pas sur la caractérisation de la faute disciplinaire[65] mais vous dirons un mot, qui sera le dernier, de la question plus délicate du choix de la sanction, de déplacement

---

[62] Il a ainsi pu déclarer lors de son audition par l'Inspection générale de la justice : « pour moi, en tant que magistrat, dire à sa hiérarchie qu'on est en dépression, cela passe mal et c'est difficile »

[63] CE, 27 mai 2009, *H...*, n° 310943, étendu aux autres agents publics par CE, Ass., *DN...*, n° 347704

[64] Alors que votre contrôle en cassation des sanctions prononcées par le CSM statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège est plus approfondi que pour les autres juridictions disciplinaires : le juge de cassation contrôle la qualification juridique retenue par le CSM pour le choix de la sanction infligée à un magistrat du siège (CE, 30 juin 2010, *P...*, n° 325319, T. p. 934, confirmé par CE, 16 février 2024, *AY...*, n° 467367, T., après la décision *BO...* (CE, Ass., 30 décembre 2014, n° 381245, p. 443) aux termes de laquelle le juge de cassation vérifie que la sanction prononcée n'est pas « hors de proportion » avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise).

[65] Il n'est pas contesté que M. O... a dirigé seul une enquête pénale pendant près de quinze mois, ce qui est incongru compte tenu de la nature indivisible et hiérarchisée du parquet, en-dehors de ses attributions, sans en référer à sa hiérarchie, en s'appuyant sur les services de police judiciaire dont les responsables étaient de ses connaissances, et qui a conduit à des interpellations, des gardes à vue, des perquisitions et des saisines. Si le CSM, et à sa suite le garde des sceaux, ont pu caractériser ces faits comme des manquements aux devoirs de loyauté et d'impartialité, qualifications qui ne sont d'ailleurs pas contestées par la requête, mais aussi au devoir de probité, même en l'absence d'intéressement financier ou matériel retiré par M. O... de la conduite de cette procédure, c'est nous semble-t-il en considération de la rupture d'égalité devant le service public de la justice dont M. O... a fait bénéficier une personne de son entourage en exerçant en toute discrétion de nombreuses prérogatives du ministère public. Quant au manquement au devoir de délicatesse, il s'appuie sur un défaut d'implication et d'investissement au sein du parquet de Bordeaux qui ressort nettement des pièces du dossier, et

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

d'office, dont M. O... soutient qu'elle n'est pas adaptée à sa situation familiale, au vu particulièrement de la fragilité de l'état de santé de son fils cadet, dont il démontre avec vigueur et nous semble-t-il conviction qu'elle nécessite sa présence au sein du foyer ; ce qui a d'ailleurs justifié qu'elle soit suspendue, le 18 janvier, par votre juge des référés. Il nous semble toutefois que si elle n'est peut-être pas adaptée à sa situation personnelle, cette sanction de déplacement d'office l'est à la nature du manquement qui lui est reproché, et qui tient à l'intrication des relations personnelles et professionnelles entretenues par M. O… avec les acteurs du monde judiciaire dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui justifiait pleinement, en tout cas à la date à laquelle la décision a été prise par le garde des sceaux, son éloignement de ce tribunal. Aucune autre sanction n'était donc adaptée, et à défaut d'autre solution satisfaisante, il nous faut gager que M. O…, de concert avec la direction des services judiciaires, trouvera dans la carte judiciaire et le statut de la magistrature les flexibilités suffisantes pour concilier la nécessaire exécution de cette sanction et les impératifs de sa vie familiale.

PCMNC au rejet de la requête.

---

dont les difficultés personnelles de M. O..., qui les expliquent en partie, ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité, son état mental n'étant pas tel qu'il ait conduit à une abolition de son discernement (v. par ex. CE, 15 juin 1955 Laborde p. 320, 8 juin 1966 F…, p. 380, 30 juin 2010, *P*..., n° 325319 et plus récemment 10 juillet 2023, Honorat, n° 458534, 16 février 2024, *AY*..., n° 467367. A contrario : juillet 1980 Centre hospitalier de Saint Quentin p. 297 ; 15 octobre 2020, BR…, n° 438488)

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.